

1501690-91.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... que o denunciado praticava o tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo algumas porções de cocaína, sendo que permanecia no local dos fatos aguardando os usuários o procurarem. Policiais militares patrulhavam pelo local - conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas - quando avistaram MARCELO que, ao notar a presença policial, saiu correndo e dispensou algo ao solo. Os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501690-91.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2349763/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22120184 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3061/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2349763 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO FERREIRA WERNECK

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40

"caput", III do SISNAD

Data da Audiência:

21/02/2022

Réu Preso

Aos 21 de fevereiro de 2022, às 17 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu MARCELO FERREIRA WERNECK, acompanhado do(a) Defensor(a), Dr(a). Gilberto de Almeida Bento Dias, bem como as testemunhas arroladas MARCELO RIBEIRO DA CRUZ e Raul Fernando de Medeiros (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que

não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MARCELO FERREIRA WERNECK por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", ambos do CP, c/c art. 40, "caput", III, do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 23 de dezembro de 2021, na rua Gabriel de Lara, nº. 100, Jardim Gongaza, nesta cidade e comarca de Tatui, MARCELO FERREIRA WERNECK, qualificado nestes autos, nas imediações de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para posterior entrega a terceiros, 24 porções de cocaína, com peso bruto de 22 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo algumas porções de cocaína, sendo que permanecia no local dos fatos aguardando os usuários o procurarem. Policiais militares patrulhavam pelo local - conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas - quando avistaram MARCELO que, ao notar a presença policial, saiu correndo e dispensou algo ao solo. Os milicianos foram no encalço do denunciado e lograram detê-lo e revistá-lo, sendo com ele apreendida a quantia de R\$ 30,00 proveniente da traficância. Na sequência, os agentes públicos foram verificar o que MARCELO havia dispensado, constatando-se tratar de 24 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem entregues ao consumo de terceiros. Em solo policial, o investigado confessou o tráfico. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva às fls. 41/2. Auto de exibição e apreensão às fls. 7/8. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 9. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 114/7. Informação sobre o local dos fatos às fls. 70. Notificação às fls. 94. Defesa preliminar apresentada às fls. 102, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 15/02/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 118/20). Citação às fls. 127. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, tal qual deliberei em processo envolvendo o mesmo acusado, no qual absolvido (refiro-me aos autos certificados às fls. 28 - 0004404-22.2010.8.26.0624), de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que, novamente, não emerge, do interrogatório, qualquer indício de que seja Marcelo incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Outrossim, não houve a juntada de qualquer documento médico que indique o contrário, de modo que a alegada utilização de cocaína restou isolada em suas palavras. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é

descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurto dúbidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]"

(v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Ainda, preliminarmente, na esteira do registro de fls. 89, observo que ao negar o oferecimento do acordo de não persecução na cota de oferecimento da denúncia, o titular da ação penal o fez de forma fundamentada, inexistindo pertinência ou espaço para a intervenção judicial. Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede, em parte, merecendo afastamento a causa de aumento de pena do art. 40, III, da lei de regência. Com efeito, feita essa ressalva que adiante será

justificada, autoria e materialidade delitivas do crime descrito na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Pois bem, dos depoimentos dos policiais Marcelo e Raul (faz-se uma síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições, exaradas por servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuam para distorcer cenário e inventar confissão informal com vistas a prejudicar inocente a quem sequer conheciam), depreende-se que patrulhando pela região indicada na denúncia, depararam-se com Marcelo, o qual, em contrapartida, correu e dispensou algo, motivando perseguição e abordagem (então apreendidos R\$30,00), na sequência verificado que aquilo do que se desfizera se tratava de 24 porções de cocaína, cuja potencialidade lesiva encontra-se aferida no laudo de fls. 114/4: 20,07 gramas líquidos, e ouvida do acusado a informal confissão. Interrogado, doravante alterando a versão de solo policial, fls. 12, Marcelo disse que na ocasião confessou, inclusive ao delegado, porque estava bêbado, quando, na verdade, a droga fora adquirida para o seu exclusivo uso, de um traficante que conseguiu se evadir, razão do desgosto dos policiais militares, que então disseram que ele pagaria por isso. Não convence de forma alguma a versão do interrogado. Conquanto tenha sido absolvido por este mesmo juízo em episódio similar, já referido, e casual a abordagem aqui versada, fato é que, ao contrário daquela oportunidade, doravante Marcelo trazia consigo considerável quantidade de cocaína, 24 porções de peso líquido médio aproximado de mais de 0,8 gramas líquidos, montante incompatível com a alegação de custódia para uso próprio por parte de alguém que, suas palavras, estaria alcoolizado e na "abstinência da droga", ainda que um dos militares (Marcelo) tenha reportado aparente alteração por causa inespecificada, máxime porque, aquele que seria um usuário contumaz, também mantinha consigo dinheiro, ainda que em total não expressivo, R\$30,00 e tentou fuga, antes de confessar informal e formalmente em solo policial. A propósito, porções na pesagem apreendida, custam, a experiência da atuação nesta vara criminal há cerca de sete anos permite afirmar, em torno de R\$30,00 a unidade, ou seja, eram mais mais de setecentos reais em estoque. Enfim, a despeito de casual a abordagem, desta feita, os policiais elucidaram com êxito um cenário de tráfico de drogas, encontrando não apenas a danosa cocaína em quantidade nada desprezível, quanto um averiguado com dinheiro e tentando escapar da abordagem, até que admitiu informal e formalmente. Preenchido, pois, o tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, ao menos sob a modalidade trazer consigo entorpecentes destinados ao comércio, para o que não se exige seja o agente apanhado em efetivo ato negocial. Dinheiro, naturalmente relacionado ao tráfico em contexto dessa natureza, deve ter sua perda declarada. Merece afastamento, no entanto, a causa de aumento atinente à proximidade de estabelecimento com a característica daqueles elencados no art. 40, III, da Lei de Drogas, e isso agora explico salientando, a uma, que a distância entre o local da abordagem e os estabelecimentos apontados pelo titular da ação penal, com base nos documentos que diligentemente acostou às fls. 129/134 (assim corrigindo a impropriedade daquele encartado às fls. 70, o qual também ensejou equívoco deste magistrado durante a oitiva do PM Raul, mas que se refere a município distinto), mormente com a Escola, é superior a duzentos metros, parâmetro utilizado pelo Juízo, e que merece ser respeitado em atenção à isonomia e segurança jurídicas, pelo menos para aqueles adstritos aos julgados desta Vara, a duas, que não se tem notícia (pelo horário da abordagem, período noturno, lembrado que fora casual, não se tendo segurança para afirmar que aquele fosse o ponto do traficante) de que a Escola estivesse aberta, e nem mesmo os policiais se recordaram disso, seja para o estabelecimento de ensino, seja para os religiosos e, a três, e por fim, o estabelecimento tipo Igreja, respeitados os posicionamentos contrários, não preenche a tipicidade legal em questão. Em suma, não há elemento seguro que permita atestar ter sido o interesse penalmente tutelado colocado em maior risco de molde a atrair a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, exceção feita à causa de aumento, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, uma vez que, a despeito de não vultosa, a quantidade da danosa cocaína apreendida, também não é desprezível, estoque

avaliado em mais de setecentos reais, a superar a média das apreensões nesta Comarca, além do que o réu apresenta histórico de evasão no cumprimento de pena pretérita (fls. 109, episódio do ano de 2014) e isso indica resistência os propósitos ressocializadores e consequente inadequação da conduta, razões pelas quais elevo moderadamente a reprimenda, em 1/10, estabelecendo-a em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à minguia de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Incide, ainda, a agravante da reincidência, específica, no crime de tráfico de drogas (certidão às fls. 28 e sua combinação com a informação na F.A às fls. 109/10, a atestar o término do cumprimento da respectiva pena dentro dos cinco anos anteriores ao flagrante aqui versado), e em função delas, elevo em 1/2 a pena retro, atingindo 08 anos e 03 meses de reclusão e 825 dias-multa. Registre-se que não houve confissão, uma vez que o acusado retratou aquela de solo policial, que já não se mostrava imprescindível para a conclusão aqui obtida, doravante admitindo posse para uso próprio, apenas. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, para além de reincidente, o que por si só veda a concessão da benesse, o é sob a forma específica, a indicar faça do tráfico o seu meio de vida, tanto que apanhado na posse de droga nefasta, cocaína, em quantidade não desprezível. Regime de cumprimento será o inicial fechado, pois, os investimentos ressocializadores, até agora não alcançados em face de indivíduo que, inclusive, evadiu-se em cumprimento pretérito, devem vir incisivos em face de reincidente específico. Não fosse isso tudo, quanto à alternatividade, é vedada tão só pela quantidade de reprimenda. Convém lembrar que o tráfico, é crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, frisado que esse delito vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para afastada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR o Réu MARCELO FERREIRA WERNECK, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 825 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por reincidente específico que registra episódio de evasão no cumprimento de pena pretérita, doravante apanhado traficando com não desprezível quantidade da danosa cocaína, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol

de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 95). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA